

1500887-97.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... com o acusado se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

O réu estava na posse de quantidade e variedade de entorpecentes incompatível para a figura de um simples usuário. A par disso, estava em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas. Certamente estava ali para o fim de vender drogas na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500887-97.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500887-97.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127406/2022 - DEL.POL.ITAPEVI, 24883430 -

DEL.POL.ITAPEVI, 2127406 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREWS LEAFAR SILVESTRE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

ANDREWS LEAFAR SILVESTRE DA SILVA, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e 329 do CP, na forma do art. 69 desse diploma legal.

Isso porque, no dia 10 de maio de 2022, às 17h15min, na Rua Fluminense, n.º 25, Jardim Itauass, nesta cidade e Comarca de Itapevi, o réu trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o réu opôs-se à execução de sua prisão em flagrante, mediante violência ao policial militar Milton Cesar Rodrigues dos Reis, funcionário competente para executá-la.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (f. 103-105).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial

acusatória foi recebida por decisão datada de 20 de junho de 2022, na qual também restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do réu (f. 116-118). O réu foi citado (f. 145), dando-se seguimento à persecução penal em Juízo. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 155). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais (f. 153-154).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática das infrações penais previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 329 do CP, praticadas em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 14-15, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse do acusado.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 95-97), sendo que o resultado foi positivo para "crack", "cocaína" e "maconha", drogas de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, tem-se que os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relatam que, na data dos fatos, receberam, pelo disque-denúncia, uma informação de que um indivíduo estava traficando entorpecentes naquele local, tendo o denunciante anônimo descrito as características físicas da pessoa. Dirigiram-se, então, até o local indicado e, lá, avistaram o acusado com uma mochila em suas costas. O réu tentou evadir-se e foi acompanhado pelos policiais, que o viram dispensando a mochila pelo caminho. Alcançaram-no e abordaram-no; pegaram, também, a mochila dispensada por ele, que continha drogas em seu interior. Quando um dos policiais deu-lhe voz de prisão, o acusado resistiu, sendo necessário o uso de força física para contê-lo até a chegada da viatura ostensiva. O acusado desferiu socos e chutes no policial no momento da resistência; não houve, porém, lesões na testemunha.

As testemunhas contrariam a denúncia, contudo, no tocante ao local dos fatos.

Referem que o crime ocorreu na Rua Bruxelas, e não no logradouro descrito na denúncia.

O réu alega em seu interrogatório que é usuário e estava no local apenas para comprar maconha. Correu quando viu a presença da viatura e diz que não estava com nenhuma mochila.

Está isolada nos autos, contudo, a versão do réu de que não estava traficando e era apenas usuário, não estando em posse da mochila.

Aliás, em juízo, afirma não conhecer os policiais militares que realizaram a abordagem, não sabendo indicar por que razão eles o acusariam falsamente.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais militares de incriminar injustamente o acusado. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais militares, permitem presumir que as drogas apreendidas com o acusado se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

O réu estava na posse de quantidade e variedade de entorpecentes incompatível para a figura de um simples usuário. A par disso, estava em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas. Certamente estava ali para o fim de vender drogas na região.

Nesses termos, nota-se que a negativa do réu em nada desqualifica a versão dos policiais militares, já que ausentes relatos contrapostos ou contraditórios.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à aplicação da circunstância privilegiadora, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, revendo posicionamento anterior e tendo em vista os recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, não vislumbro inconstitucionalidade na incidência da causa de diminuição de pena. Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: “O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”.

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”.

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação da privilegiadora ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas em seu poder (69,61g de cocaína, 45,69g de crack, 384,76g de maconha – f. 103-105) torna não recomendável o reconhecimento da minorante, já que sinaliza que está inserido no meio criminoso, possuindo certa estrutura para o tráfico.

Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

No mais, quanto ao crime de resistência, embora o réu tenha negado a prática do delito, os fatos narrados na exordial acusatória restaram demonstrados. Com efeito, o policial militar Milton César Rodrigues dos Reis, questionado se sofreu alguma agressão do denunciado, afirma que sim, que o acusado desferiu contra ele socos e chutes para tentar elidir a prisão. O policial militar Mário Nunes Corrêa, por sua vez, corrobora esse testemunho e assevera que o réu resistiu à prisão e praticou violência física contra seu colega de trabalho.

Aliás, o policial militar Edvaldo Bueno da Cruz Júnior, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, afirma que, quando chegou ao local, o acusado já estava contido e tanto ele quanto o policial militar Milton César Rodrigues dos Reis tinham arranhões em seus rostos, em virtude das agressões trocadas quando houve a resistência à prisão.

E vale frisar, em atenção à tese defensiva, que a realização de perícia no policial militar que sofreu as agressões é despicienda, notadamente porque a própria vítima afirmou que as agressões não deixaram vestígios dignos de serem constatados por laudo pericial.

Esse fato, contudo, não afasta a materialidade do delito de resistência, porque a prova oral colhida em juízo é idônea para a comprovação do delito. Aliás:

Apelação criminal – Extorsão mediante sequestro qualificada – (...) Mérito – Extorsão mediante sequestro qualificada – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima maior de 60 anos que, abordada mediante grave ameaça e violência, foi levada para um cativado, onde foi mantida por 33 dias. Policiais Civis que, após investigações, inclusive com interceptações telefônicas, efetuaram a prisão em flagrante dos acusados – Provas amplamente desfavoráveis aos réus – Fatos que se subsumem ao crime de extorsão qualificada, previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal. Condenação de rigor. Resistência praticada pelo réu Douglas – Autoria e materialidade igualmente comprovadas – Depoimentos seguros dos Policiais Civis narrando que o acusado Douglas reagiu à prisão – Ausência de laudo pericial que, por si só, não possui o condão de isentar o réu da responsabilidade penal, uma vez que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, consoante dispõe o art. 167, do Código de Processo Penal – Condenação que se mantém. (...) Recurso de Douglas parcialmente provido para reduzir a pena aplicada ao delito de resistência, com a fixação regime inicial semiaberto para tal crime. (TJSP, Apelação Criminal n.º 0001649-74.2013.8.26.0606, 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator Ely Amioka, julgado em 16/08/2018)

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção das condutas do acusado aos tipos penais previstos nos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e 329 do CP, uma vez que, com vontade e consciência, trazia consigo as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Os fatos são ilícitos, pois reprovados pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu ANDREWS LEAFAR SILVESTRE DA SILVA, já qualificado, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e do art. 329 do CP, na forma do art. 69 do CP.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8

(oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais" (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP - "personalidade e conduta social do agente". Outrossim, tem-se que "a natureza e a quantidade da substância ou produto" podem ser analisadas no contexto das "circunstâncias" do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da "preponderância" prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima - personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena - ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o acusado não ostenta antecedentes criminais aptos a exasperar a pena nesta primeira fase da dosimetria, nos termos da Súmula n.º 444 do C. STJ.

Por outro lado, o réu, em seu interrogatório, afirmou ser usuário de drogas e consumi-las com frequência, aduzindo, inclusive, que usa drogas há mais de cinco anos. Tal circunstância é desfavorável à conduta social do denunciado, já que, além de traficar drogas, financia indiretamente esse delito equiparado a hediondo, crime esse que vem, cada vez mais, corroendo famílias e a própria sociedade.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo uma circunstância judicial negativa (preponderante em relação ao crime de tráfico de drogas), assim fixo as penas-bases: a) do delito de tráfico ilícito de entorpecentes em 06 anos e 08 meses de reclusão - e 666 dias-multa; e b) do delito de resistência em 04 meses e 20 dias de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho as penas acima estipuladas, provisoriamente.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo as reprimendas, agora definitivamente, em: a) 06 (seis) anos e

08 (oito) meses de reclusão - e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes; e b) 02 (dois) meses e 20 dias de detenção para o crime de resistência.

Aplicando-se a regra do art. 69 do CP, tem-se: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 20 dias de detenção; 666 dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais.

Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra. Expeça-se a guia de execução provisória.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 29 de agosto de 2022.